

1501737-76.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... da lei de crime hediondos a hipóteses de tráfico privilegiado, como o presente caso:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA .1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1501737-76.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501737-76.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON CARLOS DE MOURA ANDRADE e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

ANDERSON CARLOS DE MOURA ANDRADE e EUGÊNIO FERREIRA GALDINO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, conforme consta, na noite de 29 de junho de 2021, por volta de 22:30 horas, na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), km 204, nesta cidade e comarca de Arujá-SP, traziam consigo e transportavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, dois tabletes de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 1000 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo narra a exordial acusatória, na data dos fatos, os acusados transportavam, no interior do veículo Chevrolet Classic, de placas DQF 3677 - São José dos Campos/SP, dois tabletes de maconha, cada um deles pesando cerca de 500g. Ocorre que, na praça de pedágio, sentido SP-RJ, o automóvel foi parado em fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal. Neste momento, os acusados jogaram, pela janela dianteira do passageiro, os dois tabletes de maconha. Questionados pelos Policiais, os acusados informaram que pegaram a droga em Guarulhos e a levariam até São José dos Campos. Inicialmente, declararam que receberiam R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo transporte, contudo, posteriormente, afirmaram que o

pagamento seria feito por meio de porções de droga.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02). Boletim de ocorrência (fls. 07/10). Auto de exibição e apreensão (fls. 21/22). Laudo de constatação (fls. 12/14). Laudo definitivo (fls. 190/192). Folha de antecedentes (fls. 242/245 e 248/250).

Concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares substitutivas em 12/05/2022 (fls. 299/300), sendo cumprido o alvará de soltura em 12/05/2022 (fls. 304 e 308).

Os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 154/156 e 161/171), sendo recebida a denúncia e designada audiência de instrução (fls. 204/205).

Sobreveio audiência, na qual foram ouvidas duas testemunhas e interrogados os réus ao final (fls. 289/292).

Em sede de alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela procedência da pretensão punitiva, nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, observou que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo. Na segunda fase postulou pela atenuante da confissão para ambos os acusados, inexistentes agravantes a serem aplicadas. Por fim, na terceira fase, diante da primariedade dos acusados entende cabível para ambos a aplicação do §4º do art. 33º, podendo impor aos acusados o regime inicial aberto, ou ainda, a aplicação de penas restritivas de direito, em substituição a eventual pena privativa de liberdade.

Por sua vez, a defesa do acusado Anderson, em alegações finais orais, aduziu que em caso de procedência seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, além de ser reconhecido o tráfico privilegiado com aplicação do redutor em seu patamar máximo. Já a defesa do acusado Eugênio, em alegações finais orais, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, além de ser reconhecido o tráfico privilegiado em seu patamar máximo, nos termos do quanto postulado pelo Ministério Público e tendo em vista sua primariedade.

Vieram-me os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A pretensão punitiva merece ser julgada procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e prova oral.

A autoria segue a mesma sorte.

Passo à análise da prova oral colhida.

A testemunha River Rosa Sobires, policial rodoviário federal, narrou que estava em fiscalização de rotina no pedágio de Arujá, km 204, Rodovia Presidente Dutra, estavam realizando um bloqueio estático, ao avistarem o veículo dos réus, eles demonstraram grande nervosismo ao visualizarem o bloqueio policial, por esta razão foi dada ordem de parada e indicado o local para parada. Pararam com o veículo um pouco a frente do local indicado, e foi possível visualizar que foram arremessados dois pacotes pela janela do passageiro,. Diante disso foi ordenado que descessem do carro, foi feita a busca pessoal em ambos, nada de ilícito foi encontrado com eles, e ao verificar os pacotes arremessados, verificou-se tratar da droga Skank, no momento da abordagem, o passageiro negou saber que se tratava de droga, dizendo que o motorista havia lhe pedido para arremessar os pacotes pela janela, o motorista assumiu que sabia que era drogas, e que recebeu a quantia de R\$ 1500,00, para transportar a droga de São Paulo à São Jose dos Campos, mas depois disse que receberia apenas uma parte da droga como pagamento. Não se recorda se falaram o motivo de estar os dois no carro.

A testemunha Robson da Silva Dainesi, policial rodoviário federal, relatou que na noite dos fatos, estavam fazendo comando estático, e visualizaram o veículo classic, prata, ao se aproximar da cabine de pedágio, o condutor e passageiro ao perceber a fiscalização da policia, começaram a mudar de atitude e demonstraram nervosismo, por esta razão seu colega decidiu abordá-los, se lembra que não pararam no local exato determinado para abordagem, pararam um pouco a frente, e o passageiro jogou dois invólucros pela janela, na busca pessoal em ambos, não foi

encontrado nada de ilícito, mas ao verificarem o pacote perceberam a substância similar a maconha, o que posteriormente foi constatado pela perícia tratar-se de Skank, acredita que o condutor era o acusado Anderson, que de pronto assumiu que estava fazendo o transporte, pegou a droga antes do pedágio, não se recorda o município, mas que levaria até São Jose dos Campos, e que ganharia uma quantia em dinheiro e que daria um parte ao passageiro, e ao indagar o passageiro, sobre o que se tratava, ele disse que desconhecia se tratar de droga, disse apenas que Anderson pediu que ele jogasse os pacotes, para que não fosse encontrado pela polícia na verificação. Pelo que se recorda, disseram que eram amigos, o condutor disse que tinha conhecimento que tratava-se de droga e que estava fazendo o transporte da droga, e que receberia certa quantia que daria uma parte o passageiro, depois ele disse que receberia uma parte da droga e que dividira com o outro acusado.

O réu Anderson Carlos de Moura Andrade, disse que tem 45 anos de idade, é motorista de ônibus, autônomo, ganha R\$ 1.600,00, estudou até o primeiro grau completo, sabe ler e escrever, é solteiro, tem um filho e nunca foi processado antes. Confirmou serem verdadeiros os fatos. Relatou que estava transportando a droga, que mora próximo ao acusado Eugênio, e que são usuários, foi até a casa dele, chamou ele para irem comprar maconha pra fumar, ao chegar no local o traficante ofereceu a ele a quantia de R\$ 500,00, iriam dividir esse valor, mais 50g de droga, que também iriam dividir. Afirmou que Eugênio sabia, ele estava junto no momento que o traficante fez a proposta, e que na hora da abordagem entraram em pânico, e por isso pediu para ele arremessar os dois pacotes. Disse ainda que aceitou a proposta porque estava passando necessidade, estava desempregado, porque cuidava de seu pai, que quando veio a falecer, ficaram apenas com a aposentadoria de sua mãe.

O réu Eugênio Ferreira Galdino, disse que tem 24 anos de idade, no momento não estava trabalhando, cursou o ensino médio completo, sabe ler e escrever, nunca foi processado antes. Confirmou serem verdadeiros os fatos. Relatou que foram buscar maconha para fumar, e chegando no local o rapaz fez a proposta pela eles buscarem a droga, sendo 1kg de maconha, em troca ofereceu R\$ 500,00 e mais 50g, de droga, para dividirem. Foram até o local para pegar a droga, era uma rua sem saída, lá o cara falou para seguirem ele, o seguiram por uns 10 minutos, após lhes foi entregue a droga, após foram embora e ao chegarem no pedágio foram presos. Disse que esta arrependido, pediu desculpa a sociedade, e pediu uma oportunidade para voltar para casa, pois é enfermo e fica difícil controlar sua enfermidade.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em solo policial os policiais apresentaram o relato de como se deu a abordagem dos réus (fls. 03/04), de forma harmônica com o que foi declarado em juízo. Os réus preferiram exercer seu direito constitucional ao silêncio (fl. 05/06).

Observa-se que segundo relato dos agentes da lei, durante a abordagem de rotina notaram o nervosismo dos réus, decidindo por abordá-los. Ocorre que os acusados não pararam o veículo no local indicado, mas mais adiante, momento em que atiraram dois pacotes para fora do automóvel, que foram posteriormente localizados e continham as drogas supramencionadas.

Os acusados confessaram o cometimento do delito, afirmando que são usuários de drogas e que na data dos fatos foram comprar droga, e lhes foi proposto que transportassem a droga, em troca de uma porção de drogas de 50g, mais a quantia de R\$ 500,00, que seria dividida entre os dois, sendo posteriormente abordados por policiais, corroborando, desta forma, o relato oferecido pelas testemunhas policiais ouvidas.

Ainda, o exame toxicológico confirmou a natureza entorpecente das drogas localizadas (fls. 12/14 e 190/192).

As versões dos réus e da acusação, na maioria dos pontos, acabam se encontrando. Assim, em relação ao transporte da droga pelos réus, em veículo de propriedade de um deles, não subsistem dúvidas.

O flagrante é inquestionável e as palavras coerentes e incriminatórias dos policiais são suficientes, haja vista que estão em conformidade com as demais provas dos autos, mormente ante a versão confessional apresentada pelos réus.

Recorda-se, no mais, que o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação

múltipla, de modo que se consuma com qualquer das outras condutas descritas no mencionado dispositivo legal, como, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente.

Vê-se, assim, que a prova amealhada durante a instrução processual é suficiente para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas pelos acusados.

Não obstante, a despeito da demonstração da culpabilidade dos acusados, algumas considerações merecem ser tecidas, e que carecem de valoração, especialmente para fins de individualização da pena.

Com efeito, os elementos amealhados aos autos não permitem concluir pela existência de um comportamento delitivo contumaz ou reiterado.

No caso em questão, os acusados são dois indivíduos com 46 e 24 anos de idade, sem antecedentes criminais (fls. 251/253), indicando em seus relatos que exerciam, ao menos ao tempo da sua prisão, labor regular, além de possuírem residência fixa.

Assim, considerando esses elementos, o histórico dos acusados e a sua vida pregressa, mas também as circunstâncias do caso, não é desarrazoado concluir que os acusados atuaram como "mula" do tráfico.

Também não se deve olvidar que, segundo relato dos policiais, os réus manifestaram extremo nervosismo durante a abordagem, demonstrando, com isso, uma inexperiência considerável na consecução do delito. Em outras palavras, os acusados pareceram portar-se como alguém que de fato não estaria habituado com a dinâmica delituosa. Outrossim, é preciso destacar que com os acusados não foram encontrados quaisquer outros objetos, tais como anotações, cadernos de contabilidade, e outros que pudessem vinculá-los, de uma forma mais estável ou permanente, ao comércio espúrio. Também não foi localizado qualquer armamento ou quantia expressiva de dinheiro em seu poder.

No mais, a despeito da quantidade de droga apreendida ser considerável, também não é absurdamente expressiva (978,00g de massa líquida) quando comparada a outras apreensões.

E muito embora tal droga tenha provável origem em organização criminosa mais estruturada, conquanto esta não tenha sido minimamente identificada, o simples fato de os réus a terem transportado, não constitui, à vista das circunstâncias constantes dos autos, elemento probatório idôneo suficiente a concluir, com a segurança necessária, que os acusados seriam efetivamente integrantes de organização criminosa.

Tal conclusão vem reforçada também pela oitiva dos policiais e pela versão dos réus, concluindo-se que os averiguados receberiam em pagamento pelo transporte da droga a quantia de R\$ 500,00, além de 50g do entorpecente, o que termina por indicar, no entender deste juízo, uma atuação eventual dos acusados.

Com efeito, da análise dos autos, só se pode extrair que os réus agiram como transportadores eventuais, mormente diante de seu histórico pessoal escorreito, não sendo possível afirmar que os acusados integram organização criminosa, pois para que isto fique manifesto, é necessário que se verifique espontânea vontade de integrar a associação, além de fazer da criminalidade seu meio de vida principal, com habitualidade criminosa, não sendo este o caso de pessoas que são ocasional ou eventualmente cooptadas por tais organizações a praticarem delitos específicos.

Assim, à vista das circunstâncias explanadas, não sendo possível concluir ser os réus integrantes de organização criminosa, não haveria motivos idôneos a afastar a incidência do parágrafo 4º do art. 33 da lei 11.343 ao caso em questão.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso especial da acusação para afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas; b) entre a sua prisão em flagrante e o julgamento de recurso de apelação em que se buscava o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, cumpriu-se integralmente a pena, tendo sido extinta sua punibilidade; c) sobreveio, então, o ato coator, dando-se sequência à execução da

pena privativa de liberdade, redimensionada para 5 anos de reclusão. Busca-se a detração com a alteração do regime de continuação da execução. É o relatório.

Decido. 1. Cabimento do habeas corpus: A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: "O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal." (HC 128693 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) "O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal." (HC 123430, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) "(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior." (HC 86367, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) No caso concreto, extrai-se dos autos (eDOC 10, p. 74) que o ato coator transitou em julgado em 15.3.2018. Assim, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 2. Contudo, no que se refere ao afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, verifico a existência de constrangimento ilegal, passível de conhecimento de plano. No caso concreto, o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu pela manutenção do redutor com base nos seguintes fundamentos (eDOC 10, pp. 65-66): Em relação à terceira fase de aplicação da pena, pleiteou o Parquet o afastamento da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao argumento de que o acusado se dedicava às atividades criminosas. Sem razão o órgão acusador. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que embora Jean Carlos tenha sido surpreendido em flagrante após ter sido constatado pelo serviço de inteligência da Polícia Federal o transporte da droga, nada nos autos menciona a respeito de outras atividades ilícitas por ele praticadas. Não há informações nos autos no que tange às investigações anteriormente realizadas, limitando-se os agentes policiais a indicar a respeito apenas da apreensão. Ademais, a meu ver, é dever da acusação trazer para os autos, de forma inequívoca, as informações que têm o condão de incrementar as penas, não havendo, no presente feito, qualquer anotação neste sentido. Assim, não havendo provas suficientes de que o acusado fazia do comércio ilícito seu meio de vida, dedicando-se à atividade criminosa, é possível afirmar que o caso presente se revele como uma ocorrência isolada, o que permite a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas. 2.1. Como se nota, no que atine ao afastamento do redutor, a motivação do Superior Tribunal de Justiça está centrada na expressiva quantidade de droga, superior a 108 kg (cento e oito quilogramas) de cocaína, bem como na constatação da existência de "acordo de recebimento da importância de R\$ 2.000,00 a ser paga por terceiro" para transporte daqueles tabletes, tudo a indicar a dedicação do paciente a atividades criminosas (eDOC 10, pp. 41-42). Não obstante o alto poder lesivo do entorpecente apreendido, não é possível fazer tal ilação sem o suporte de outros elementos fático-probatórios. Segundo a jurisprudência do STF, "[a] quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa" (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017). Com efeito, a quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, notadamente se evidenciada, como no caso dos autos, a mera condição de transportador do paciente, bem como, a partir do que as decisões proferidas permitem observar, o preenchimento dos demais requisitos previstos na minorante. Afirmou o TJMG que "nada nos autos menciona a respeito de outras atividades ilícitas por ele praticadas". O paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de cocaína, conduta pela qual receberia remuneração. Contudo, à míngua de outros elementos probatórios, não há qualquer indicativo de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. A Segunda Turma do

STF tem posição firme no sentido de que a condição de "mula" ou a mera alusão ao fato de ter efetuado o transporte de entorpecentes (ainda que entre Estados da Federação), por si só, não impede a incidência da minorante. Para fins de individualização da pena, a singela alusão genérica à importância dos transportadores na estrutura de uma suposta organização criminosa não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional. Na mesma linha: "Incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas afastada pelas instâncias de mérito com amparo em mera conjectura ou ilação de que os pacientes integrariam organização criminosa, já que recrutados para transportar drogas ao exterior (mulas do tráfico). Inexistência de base empírica idônea. Constrangimento ilegal configurado. Habeas corpus concedido de ofício. (...) O exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga." (HC 124107, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 04.11.2014, grifei). "PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO NA FRAÇÃO DE 1/3. PRECEDENTES. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido benefício (cf. justificativa ao Projeto de Lei 115/2002 apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação). 2. No caso, o Tribunal de apelação afastou a referida minorante com base em argumentos genéricos e teóricos, desprovidos de qualquer elemento contido nos autos, senão no fato de a paciente ter sido condenada pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas. Por outro lado, a sentença condenatória afirmou, de forma segura, a inexistência de prova apta a justificar a negativa da causa de diminuição. Precedentes. 3. Ordem parcialmente concedida." (HC 124022, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). Dito isso, não visualizo qualquer fundamento hábil a negar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao paciente. 4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a minorante, devendo a pena do paciente seguir os moldes fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora com cópia do inteiro teor desta decisão. Comunique-se, outrossim, ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente. (STF - HC: 181268 MG - MINAS GERAIS 0086299-90.2020.1.00.0000, Relator: Min. EDSO FACHIN, Data de Julgamento: 14/02/2020, Data de Publicação: DJe-035 19/02/2020). (grifos nossos)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AGENTE NA CONDIÇÃO DE "MULA". PLEITO DE DECOTE DESSA MINORANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A orientação jurisprudencial desta Casa, na linha do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que "o fato de o agente haver atuado como 'mula' no transporte da droga não pode - como numa relação, pura e simples, de causa e efeito - levar à conclusão de que ele seria integrante de organização criminosa e, como tal, não seria merecedor da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A diferenciação deve ser feita, inequivocamente, caso a caso, com base em elementos objetivos e concretos dos autos (Resp n. 1.365.002/MS, relator Ministro ROGERIO

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017). 2. No caso dos autos, o colegiado estadual, respeitando os critérios legais estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, ainda, com observância aos pormenores da situação concreta, entendeu que inexistiam nos autos provas que demonstrassem a dedicação do agravado às atividades criminosas ou de que integrasse organização criminosa, embora tenha sido apreendida grande quantidade de entorpecente, qual seja, mais de 32kg (trinta e dois quilos) de maconha. 3. Nesse contexto, para que fosse possível a análise da pretensão recursal de decote dessa minorante, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1532159 MT 2019/0190378-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). (grifos nossos).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME QUE DENOTA HABITUALIDADE DELITIVA. EVIDENCIADA AINDA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em 13 de novembro de 2019, com pedido de liminar, em favor de Pedro Eduardo Costa de Oliveira, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE. 2. Compulsando os fólios, depreende-se que não assiste razão à defesa, 1) seja porque entendo que a imputação realizada pelos órgãos persecutórios da integração do paciente à organização criminosa é suficiente para comprovar o seu perigo à ordem pública, em razão da habitualidade criminosa ser inerente a esse tipo penal; 2) seja porque entendo estar presente nos autos provas da sua periculosidade concreta; Senão vejamos. 3. A organização criminosa está relacionada à atuação da delinquência estruturada, que visa afrontar diária e habitualmente bens jurídicos fundamentais para o Estado Democrático de Direito. Assim sendo, o indivíduo que decide por livre e espontânea vontade integrar determinada associação, deve ser considerado como uma pessoa que faz da criminalidade seu meio de vida principal. Não estamos aqui a tratar das pessoas que ocasionalmente são cooptadas ou coagidas por essas organizações a praticarem delitos específicos - como, por exemplo, nos casos das 'mulas do tráfico' -, mas sim daquelas que decidiram fazer parte permanentemente da organização, fazendo das práticas criminosas verdadeiras profissões. 4. Ora, a habitualidade criminosa é condição de existência, portanto, condição sine qua non de uma organização criminosa, sendo a jurisprudência uníssona quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus, cujos autos evidenciam a prática habitual de delitos. Precedentes do STJ. 5. Ainda que se diga que tal indivíduo não detém nenhuma função administrativa, de comando ou de gerência, ele é parte indispensável para o todo harmônico funcionar; e ainda se beneficia, mesmo que indiretamente, do produto oriundo das atividades criminosas diárias e habituais da empresa do crime. (...) 11. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas corpus, nº 0632586-38.2019.8.06.0000, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por maioria, em CONHECER do habeas corpus impetrado, mas para DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 21 de janeiro de 2020 MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator Designado (TJ-CE - HC: 0632586382019060000 CE 0632586-38.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 21/01/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020). Grifo Nosso.

Tratando-se de acusados primários, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o réu ostenta bons antecedentes e inexistente nos autos comprovação suficiente de que se dediquem a atividade criminosa, ficando demonstrado pelas provas acostadas aos autos que os réus atuaram evidentemente como "mula". Demais disso, a quantidade de drogas, embora seja considerável, não obsta o reconhecimento da minorante.

Nesse sentido, os arestos abaixo colacionados.

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MULA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Para verificar a adequação da causa de diminuição ao caso concreto, indispensável observar tanto as condições individuais do agente quanto as da conduta em concreto praticada, de todo incabível a concessão do benefício em caso de reincidência, maus antecedentes, dedicação a atividades criminosas ou participação em grupo destinado a esse fim. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que 'o exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga', porquanto 'descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que os réus integrariam organização criminosa' (HC 124.107/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.11.2014). 4. Na hipótese, proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 2/3 (dois terços), considerada a inexistência de circunstância ou fato desabonador ensejador de aplicação de fração menor. Precedentes: HC 132.459/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, votação unânime, DJe 13.02.2017; HC 131.918/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, votação unânime, DJe 02.3.2016; e HC 123.534/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, votação unânime, DJe 10.10.2014. 5. Observados os parâmetros estabelecidos no HC 97.256/RS e no HC 111.840/ES desta Suprema Corte e consideradas a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar de 2/3 (dois) terços e "a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis", possível a fixação de regime prisional mais brando - aberto -, e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 6. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão de ofício da ordem, para determinar que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a nova dosimetria da pena, mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços), e reexamine, se o caso, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (STF - HC: 129449 SP - SÃO PAULO 0004774-62.2015.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/03/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-088 28-04-2017). (grifos nossos)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGENTE NA CONDIÇÃO DE "MULA". AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO ACERTADA. 1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente fundamentou a majoração da pena-base em 2 anos, com fundamento na natureza e quantidade de entorpecentes - 1920g de "cocaína", nos termos do art. 42 da Lei n.



11.343/2006 e art. 59 do CP, encontrando-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do caso versado. 3. Para a aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso em concreto. O legislador, entretanto, não definiu os critérios a serem adotados pelo magistrado para a escolha do percentual de redução da pena. 4. No presente caso, a opção pela fração de 1/6 foi devidamente justificada no fato de o acusado ter contribuído com organização criminosa, agindo na condição de "mula", o que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1013343/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017)

Inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou que isente os réus de pena. No mais, a ação foi culpável, reprovável, pois os réus eram (e ainda são) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de condenar ANDERSON CARLOS DE MOURA ANDRADE e EUGÊNIO FERREIRA GALDINO, qualificados no autos, como incurso nas penas do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena.

1) Réu Anderson Carlos de Moura Andrade

Circunstâncias judiciais

Assim, primeiramente, no tocante às circunstâncias judiciais, verifico que o réu agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. O réu não possui maus antecedentes (fls. 251/252). O motivo do delito se constituiu pela obtenção do lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias são normais.

Diante disso fixo a pena-base no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, no menor valor legal.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Incide a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d" do CP, visto que foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ, contudo, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, ante o teor da Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento.

Presente, todavia, como já asseverado alhures, a causa de diminuição de pena do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não possuindo antecedentes, não havendo ainda provas suficientes de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, não tendo sido produzida pela acusação nenhuma prova de vínculo aprofundado e estável com o comércio espúrio, para cujo reconhecimento seria necessária a existência de prova cabal neste sentido.

Neste ponto, vale mencionar a manifestação de César Dário Mariano:

Presentes os requisitos previstos na norma a diminuição da pena é obrigatória, não ficando ao alvedrio do Juiz operar a redução ou não. Embora a norma empregue a expressão "as penas poderão ser reduzidas", não se trata de atividade discricionária do Juízo, mas de direito subjetivo do acusado. Aliás, a primariedade e bons antecedentes deverão ser demonstrados pelo acusado, ao passo que caberá ao Ministério Público o ônus de provar que o réu se dedica à atividade criminosa ou que pertence à organização criminosa. Não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso, o Ministério Público.

(...) Dedicar-se a atividades criminosas pressupõe reiteração de condutas tipificadas como crime, ou seja, habitualidade no cometimento de delitos. Tal circunstância poderá ser demonstrada por meio de folhas de antecedentes criminais, certidões cartorárias, cópias de outros processos, testemunhas, ou seja, qualquer meio hábil a provar a vida criminosa do acusado. Como a norma não diz qual espécie de atividade criminosa poderá ser qualquer uma, desde que, obviamente, não se trate de delitos culposos, que pressupõem ausência de vontade.

A norma visa a impedir a redução da pena para aquele que de forma habitual e deliberada pratica qualquer espécie de crime. Com efeito, aquele que faz da vida criminosa seu modo de vida não é merecedor do redutor. (Silva, César Dario Mariano da Lei de drogas comentada / César Dario Mariano da Silva. -- 2. ed. -- São Paulo : APMP - Associação Paulista do Ministério Público, 2016).

Em sentido semelhante:

“A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

Outrossim, conforme explanado anteriormente, a quantidade de drogas, por si só, não pode resultar na interpretação de que o réu faz do tráfico seu meio de vida ou integra organização criminosa. Nesse sentido, em complemento aos arestos já colacionados, seguem os julgados abaixo:

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

I - A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante.

II - A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.

III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal. Precedentes.

IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. (STF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 138.715 MATO GROSSO DO SUL.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. SÚMULA 7/STJ. CONTRIBUIÇÃO DO AGENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA CONDIÇÃO DE MULA. APLICAÇÃO DO REDUTOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Assentado pelo Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, que inexistia prova da dedicação da acusada à atividade criminosa, a alteração desse entendimento enseja o revolvimento do conteúdo probatório dos autos, inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. No caso,

conforme se extrai dos excertos, o Tribunal de origem, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, concluiu motivadamente pela aplicação do redutor no patamar de 1/3, tendo em vista que a atuação da ré era típica de 'mulas do tráfico', embora tenha sido apreendida com grande quantidade de drogas (33 kg de maconha). 3. O atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria é no sentido de que a simples atuação como "mula", por si só, não induz que o réu integre organização criminosa, de forma estável e permanente, não constituindo, portanto, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor em sua totalidade, tratando-se de meras ilações, presunções ou conjecturas, até porque pode se tratar de recrutamento único e eventual (Precedentes.) 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1776471 MS 2018/0285250-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGENTE NA CONDIÇÃO DE "MULA". REDUÇÃO EM 1/3. PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos - 153 kg de cocaína - para elevar a pena-base em 3 anos e 4 meses acima do mínimo legal, o que não se mostra desproporcional. 3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/3, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Logo, devidamente motivada a escolha do patamar de redução, a alteração desse quantum é questão afeta à atividade discricionária do julgador, que só pode ser revista quando verificada sua desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 495680 SP 2019/0058485-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)

Diante disto, cabível a redução à razão de 2/3, já que somente a quantidade de drogas não é elemento suficiente a afastar a minorante ou mesmo modular a fração do benefício.

Nesse sentido, o recente julgado do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTAM PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR A FRAÇÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (RECURSO ESPECIAL Nº 1925096 - SP - RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ - Brasília, 02 de agosto de 2021). (grifos nossos).

Assim, diminuo a pena em 2/3, ficando o réu definitivamente condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão cumulada com 166 dias-multa, no mínimo legal, pena esta que torno definitiva.

Regime prisional

O parágrafo 4º do art. 33 da lei 11.343/06 de forma louvável, admitiu em casos como o ora analisado, a possibilidade de redução da pena imposta ao acusado primário e

de bons antecedentes em até 2/3. A previsão legal de uma causa de diminuição de pena nestas circunstâncias tratou de prestigiar da forma adequada o princípio constitucional da individualização da pena, reconhecendo uma situação fática que salta aos olhos do operador do direito: o de que traficantes eventuais, de bons antecedentes e que nunca se envolveram em organizações criminosas não podem ser equiparados aos grandes comerciantes de drogas, verdadeiros empresários do tráfico, responsáveis por manter toda uma rede articulada de produção e distribuição de drogas, auferindo grandes lucros da atividade e fomentando o cometimento de outros tantos delitos gravosos. Como se vê, são duas espécies distintas de criminosos a justificar tratamentos diversos pela lei penal.

Estranhamente, o próprio dispositivo legal supra aludido, de forma incongruente, negava expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa em pena restritiva de direito, afastando-se, desta feita, dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e, como tal, do próprio princípio da individualização da pena que, de início, parecia pretender alcançar.

Não há dúvida, como mencionado alhures, que a reprovabilidade da conduta do traficante ocasional é menor do que a dos grandes traficantes de droga responsáveis por coordenar e alimentar a grande cadeia do tráfico ilícito de entorpecentes. Eis a razão pela qual a nova lei de drogas, de forma feliz, reconheceu a culpabilidade atenuada daqueles pequenos criminosos, permitindo uma razoável diminuição da pena que eventualmente lhe venha a ser imposta.

Todavia, a concretização da máxima da individualização da pena não se esgota na dosagem da quantidade de pena aplicada ao réu, mas também se funda na determinação de sua qualidade ou natureza. Se a culpabilidade do réu é de menor grau, sustentando a lei uma diminuição da pena imposta, não subsiste razão jurídica para obstar ao réu a concessão de benefícios penais condizentes com a sua menor culpabilidade.

A substituição da pena privativa por restritiva de direito é mecanismo salutar e consentâneo com os primados do Estado Democrático de Direito em que vivemos, sendo, em caso como ora apresentado, bastante a demonstrar a reprovação do Estado com relação à conduta perpetrada pela agente, evitando-se assim os males que o sistema carcerário acarreta, mormente no tocante a presos que cometeram pequenos delitos, como o ora acusado.

A vedação outrora inserta no art. 33, §4º da lei 11.343/06 que impedia a substituição da pena privativa imposta revelava-se incoerente e arbitrária, destoando dos preceitos constitucionais aos quais deve estar atrelada, motivo pelo qual deveria ter sua aplicação afastada. Aliás, tal providência é hoje desnecessária, uma vez que o Senado Federal, desde 16.02.2012, seguindo a linha da jurisprudência dos tribunais, resolveu por bem baixar a resolução nº 05/2012, suspendendo a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” constante do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, de modo que desde tal data, não subsiste mais qualquer empecilho legal à substituição da pena nos casos de tráfico privilegiado.

Também afastada deve ser a regra inserta no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, por determinar o cumprimento inicial da pena imposta por tráfico de entorpecentes, sempre no regime fechado, pelas mesmas razões declinadas relativas ao dispositivo que vedava a substituição da pena.

Aliás, o próprio STF, já vem entendendo - além da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito - pela inaplicabilidade da lei de crime hediondos a hipóteses de tráfico privilegiado, como o presente caso:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA .1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência,

a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida. (HC 118533, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 16-09-2016 PUBLIC 19-09-2016)

PENA – REGIME FECHADO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990. A imposição do regime inicial fechado, prevista na Lei de Crimes Hediondos, é inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 111.840, relator o ministro Dias Toffoli, julgado